



从立案审查到立案登记： 法院在社会转型中的司法角色

陆永棣^{*}

内容提要 立案登记制的确立,标志着选择性司法的终结。但转型期人民法院通过立案审查对纠纷进行选择性的司法又有其深刻的政治、社会和法律原因。以立案登记制取代立案审查制,首先体现为法院在立案程序上已从职权模式转向诉权保障模式,更深层意义在于法院的司法角色或说职能应该有一个很大的变化。但在通过立案审查制采取选择性司法的三大因素仍然存在,在我国社会仍将处于较长时期的社会转型这一大背景下,平衡好立案登记制有诉必理、有案必立与受理“依法应该受理的案件”之间的关系,必须处理好几个方面问题:第一,把握好立案过程中登记与审查的关系;第二,确立司法有限的理念,明确受案范围;第三,倡导纠纷多元化解,尽快建立诉前强制调解程序;第四,规制与防范不当行使诉权特别是滥诉行为。

关键词 立案审查 选择性司法 立案登记

2014年10月28日,《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出:“健全公民权利救济渠道和方式”,“改革法院案件受理制度,变立案审查制为立案登记制,对人民法院依法应该受理的案件,做到有案必立、有诉必理,保障当事人诉权”。2015年4月1日,中央全面深化改革领导小组审议通过《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》。与此相应,2015年2月4日,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》开始施行,2015年5月1日,新的《中华人民共和国行政诉讼法》正式施行,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(以下简称“《解释》”)与新法同步实施。上述中央文件和最新修法,标志着人民法院主要包括民事诉讼、行政诉讼在内的立案登记制的确立。这一制度的确立是对立案审查制的修正,也可以说是从制度层面昭示了此前人民法院对起诉进行严格的审查,对社会矛盾和纠纷的介入保持相对谦抑的姿态,进而在司法政策上实行选择性司法的终结。但是,长期以来,为什么人民法院在民事诉讼和行政诉讼中坚持立案审查制,对纠

^{*} 浙江省高级人民法院高级法官,审判委员会委员。



纷实行选择性司法,立案登记制确立后司法的走向应该如何把握,这是需要我们探究的重要问题。只有真正了解了这个问题,我们才能认识人民法院在当下历史阶段的角色,真正把握我们需要的是一个什么样的登记立案制度,从而在纠纷汹涌而来甚至可以说是诉讼爆炸面前保持足够的定力。

一、立案审查与选择性司法

关于立案审查的弊端,有学者认为主要表现在两个方面:一是权限配置失衡,法院职权对当事人诉权的干预和对处分权的漠视;二是程序保障欠缺,诉讼要件被提前至起诉程序中审查。而其原因则在于对起诉条件、诉讼要件和本案要件评价体系的混乱及相应的规制原则的紊乱。^①就起诉程序而言,这一观点无疑切中要害。但是,此前的司法实践表明,相对于立案登记制,立案审查只是个表象。或者说之所以立案审查,不仅是法院在理论认知和制度构建上的问题,其实背后的指导思想也是居支配地位的司法政策,在于通过立案审查对案件进行选择性的受理。而且这个选择并不主要是法律特别是诉讼程序意义上的,其核心是对一些纠纷以政治的、社会的、习俗的等非司法因素阻挡,不予进入诉讼程序。或者说“尽管当事人提起了诉讼,而且也自认为符合起诉的条件,但诉讼却难以进入实质审理阶段的情形”。^②这也是长期不被学者待见的在案件受理上的选择性司法现象。

一般以为,司法是社会公平正义的最后一道防线,按照“司法最终解决”原则,任何一个纠纷都可以诉诸诉讼,法院不能拒绝收案、拒绝审判,而将纠纷挡在自己的大门之外。但我国自上世纪八十年代初民事诉讼法正式实施以来,特别随着改革开放深入社会深层次矛盾日益显现后,法院并没有撤除所有门槛对纠纷进行“最终解决”。通过立案审查的选择性司法现象,不仅在地方法院的司法实践和一些司法意见中屡见不鲜,最高法院也时常针对某类案件明确不予受理或限制受理。如三鹿奶粉事件所涉相关民事赔偿,就是典型的群体性敏感案件诉前分流的案件。^③不管我们承认与否,选择性司法实际上已成为一项自上而下的司法政策。其具体表现形式有三:

第一,对个案选择性的不予受理或在特定时段内不予受理。这类个案往往具有敏感、疑难、复杂的特点,而更多的纠纷是诉至法院的虽表现为个案,但其背后往往聚集相

① 参见段文波:《起诉程序的理论基础与制度前景》,载《中外法学》2015年第5期。

② 参见张卫平:《起诉难:一个中国问题的思索》,载《法学研究》2009年第6期。

③ 2008年9月至12月底,全国发现众多婴幼儿因食用包括三鹿牌在内的全国多家乳品企业生产的奶粉泌尿系统出现异常,这也就是震惊国内外的“三聚氰胺”事件。食用含三聚氰胺奶粉引起婴幼儿人体伤害系典型的人身损害赔偿纠纷,但其涉及面广、社会影响大、案件性质敏感。因此国家在政府层面成立相应的民事赔偿工作领导小组,对相关患儿根据不同的人身损害程度确定不同的赔偿方案,在较短时间内赔偿到位,有效平息了事态,避免出现可能因司法程序冗长、证据缺失事实认定困难、各地赔偿标准不一等而带来社会心理的持续动荡。最高人民法院则要求相关法院积极引导当事人依靠政府协调解决纠纷,做好法律释明,让相关受害人充分了解诉讼对证据的要求、诉讼风险、诉讼程序以及被告可能存在执行不能等情况,慎重把握司法介入时机和条件。

当大的利益群体,先案具有投石问路的性质。例如在民间金融十分发达的浙江一些地区,中小微企业主要依靠民间借贷运转,民间借贷与非法集资往往交织在一起,一旦有债务人资金链断裂,就会引起连锁反应进而爆发局部地区的借贷危机。当地政府从维护社会稳定、帮护企业发展、熔断债务链条的目的出发,前期都会主动介入牵头清理债务,打击非法集资。由此,法院对以个案形式提起的民事诉讼以及由此延伸的行政诉讼受理极为谨慎,一般情形下均将起诉引导分流至政府部门集中处理,坚持起诉的在政府集中清理期间不予受理。2012年初发生的温州立人教育集团案即为典型。^④2008年金融危机爆发以来涉及清算重整金融证券类公司的债务纠纷,债权人个案起诉的最高院也均要求暂不予受理。^⑤既使在立案登记制实施后,类似案件最高法院的态度也没有变化。

第二,对类型性案件以内部文件明确“慎重审查立案”或不予受理。这类案件往往以纪要、通知、意见的形式由最高人民法院或高级人民法院作出。而“慎重审查立案”,其实更多也是不立案的代名词。如广东高院对于外嫁女诉农村集体组织的土地征用补偿款分配纠纷,曾规定这类案件必须经相关政府部门前置处理,未经乡镇政府处理并经行政复议,法院不予受理。^⑥广西自治区高院规定十三类案件不予受理,包括:集资纠纷、企业改制导致的职工下岗纠纷和安置纠纷、村民土地补偿安置纠纷、地方政府大规模解除土地承包合同纠纷、合作化时期遗留的集体财产分割纠纷、没有明确的职工安置方案的破产申请案件,等等。^⑦山西高院要求对涉及采矿权纠纷的案件暂缓立案,暂缓审理,暂缓执行。^⑧河南高院规定,未取得采矿许可证擅自采矿引起的各种纠纷,人民法院不予受理。^⑨最高人民法院在四川汶川、青海玉树、甘肃舟曲地震泥石流等重特大自然灾害发生后,针对此类社会非正常状态下发生的纠纷,要求坚持党委统一领导,鼓励、支持人民调解等组织化解纠纷,支持行政机关运用行政手段解决纠纷;明确对于可能影响灾后恢复重建工作进行顺利、群体性以及社会比较敏感的案件,对于有关部门已经协调处理过的案件,要慎重审查立案;强调对不属于或不宜由人民法院处理的纠纷,引导

④ 如2012年2月27日,叶某某等147名债权人向温州市中级人民法院递交行政诉讼状,状告泰顺县政府和泰顺县公安局,要求法院确认两被告放任立人集团非法集资13年的行为构成行政不作为,确认两被告支持立人集团“钓鱼式集资”及正采取的“企业自救、政府帮扶”的解决债务危机的措施违法,请求两被告承担原告损失6864万元。温州中院认为该案不属于《行政诉讼法》规定的相关受案范围,不予受理。

⑤ 实际上对于证券金融机构的重整乃至破产清算,最高法院的一贯做法都是配合并强调行业监管部门的主导作用。这些年来从中信、广东国际信托、海南银行、浙江金信信托等等一系列的案件,均要求没有受理的不予受理,已经受理的中止审理,已经判决的中止执行。这一现象并非我国独有,传统意义上三权分立最为典型的美国,就是由相关监管当局负责主持金融机构的破产程序,排除普通破产法的适用或者规定优先适用特别行政程序法。参见黄韬:《我国金融机构市场退出法律机制中的权力版图》,载《中外法学》2009年第6期。

⑥ 参见贺欣:《为什么法院不受理这些纠纷——司法决定过程中的法律、权力和政治》,载《司法制度演讲录》(第一卷),法律出版社2008年版。

⑦ 参见桂高法[2003]180号《广西壮族自治区高级人民法院关于当前暂不受理几类案件的通知》。

⑧ 参见晋高法[2006]7号《山西省高级人民法院关于审理涉及煤矿矿业权民事纠纷案件若干问题的意见》。

⑨ 参见豫高法[2005]224号《河南省高级人民法院关于当前审理煤矿纠纷事件若干问题的指导意见》。

当事人选择其他途径解决。^⑩

第三,由上级法院提出原则性指导意见,一线中基层法院具体把握。这一情形最为普遍,涉及面也最广。基于对改革、发展过程中引发的一些问题,不要轻易纳入司法渠道的指导思想,最高人民法院往往强调相关纠纷案件的受理要坚持依法稳妥的原则,实现立案工作法律效果、社会效果和政治效果的统一,对于一些非受理不可的案件也应在充分了解案件背景、预测社会影响和涉及的问题的情形下再予慎重受理。当然,如何理解法律效果与社会效果,两者是否会发生冲突以及冲突时的应对,又有不同的认识。在这里,法院不过多介入其不应或不宜介入的领域,避免司法不仅不能发挥解决纠纷的功能,反而使司法的权威性受到损害,依然是包括最高法院在内受案法院考量的主要因素。^⑪

当然,法院是否应该过滤案件并将之拒之门外并不是中国法院才纠结的问题,域外的司法实践面临着相同的困惑。如香港特别行政区高等法院在香港特区政府律政司司长诉马桂珍一案中,就马桂珍女士的滥诉发布禁令,明确没有事先得到高等法院原讼法庭法官许可不准在任何法院起诉,如其试图在没有事先得到法庭的许可下在法院登记处提起任何新的诉讼,法院登记处须拒绝登录或将相关原诉文件转交指定法官予以撤销。该院认为法院有权采取适度的措施来制约诉讼人士向法院申诉的权利,以防止法律程序被人滥用。^⑫ 又如在1973年的罗伊诉德州政府案中,因美国德州法律禁止堕胎,一位化名罗伊(Jane Roe)的妇女起诉德州政府,联邦最高法院以6:3的多数意见作出支持罗伊的判决。但在美国历史上是否允许妇女堕胎是一个持续存在争议的话题。1996年,参众两院以多数票通过禁止“局部分娩”(partial birth)的反堕胎法,克林顿总统行使否决权,阻止了该法生效;到了2013年的6月18日共和党控制的众议院又通过了一项《可感知痛苦的未出生儿童保护法》,禁止妇女在怀孕20周后堕胎,法案因民主党控制的参议院未付诸表决而流产。对于两党来说死掐这个话题各有政治目的,但对法院是否应该掺和则有很大的争议。对于当时联邦最高法院的判决,有不少观点即认为司法超越了应遵守的边界。^⑬

学界对于选择性司法这一现象从2002年开始持续关注,观点褒贬不一。早在2002年,张维迎教授在题为《诉讼过程中的逆向选择及其解释——以契约纠纷的基层法院判决书为例的经验研究》一文中,通过对两千多份基层法院判决书反映的数据进行的分析,发现了“大量模糊性的纠纷现在越来越少进入法院,只有简单的案件进入法院”这一

⑩ 最高人民法院为此出台的文件包括:《关于依法做好抗震救灾期间审判工作 切实维护灾区社会稳定的通知》、《关于依法做好抗震救灾恢复重建期间民事审判和执行工作的通知》、《关于处理涉及汶川地震相关案件适用法律问题的意见(一)、(二)》、《关于依法做好青海玉树地区抗震救灾和恢复重建期间审判工作 切实维护灾区社会稳定的通知》、《关于依法做好甘肃舟曲等地区抢险救援和恢复重建期间审判工作 切实维护灾区社会稳定的通知》。

⑪ 参见王利明:《司法改革研究》,法律出版社2001年版,第141页。

⑫ 香港特别行政区高等法院原讼法庭高院杂项案件编号2005年第1471号。

⑬ 参阅方流芳:《罗伊判例:关于司法和政治分界的争辩——堕胎和美国宪法第14修正案的司法解释》,载《比较法研究》1998年第1期;《堕胎法案引美国两党死掐》,载《环球时报》2013年6月20日。



反常现象,并运用经济学的原理解释了造成这一现象的原因。^⑭ 张教授可以说是最早触及这一话题的学者之一,尽管他的观点更多是从经济学的角度阐述市场主体的主动选择,是否切合实际尚存争议。2005年,贺欣博士通过对分别处于东部沿海经济发达地区和西部经济发展相对落后、信息相对封闭地区两个基层法院的考察,提出“难以处理的案件命中注定将会被排除在现代法院的大门之外,不管是因为法院有意这样做,还是因为当事人在这种情况下选择或者不得已只能这么做。这不仅仅是中国在建立起现代性法院时出现的独特现象,类似的情况出现在现代性到来时的美国城市和农村法院。很可能这个现象是一个现代性袭来之时全球法院面临的共同问题。”^⑮2007年4月,其在西南政法大学所作的《为什么法院不受理这些纠纷——司法决定过程中的法律、权力和政治》演讲中,又以广东法院在“外嫁女”纠纷中的态度为切入点,论述了该省法院如何通过拒绝直接受理这类案件与政府进行博弈,最终迫使政府行政作为解决这类纠纷的过程及意义。^⑯ 汪庆华教授则在《中国行政诉讼:多中心主义的司法》一文中认为:“中国行政诉讼面临的最重大挑战在于整个司法过程的选择性,以及这种选择性司法带来的不确定性,从而可能形成比没有法律还要糟糕的结局。”“选择性司法所带来的最大问题在于,他可能会以司法的名义和权力站在一起,从而彻底消解民众对于法制的信心。”^⑰段文波教授提出:“在面对一些‘棘手’案件时,有些立案庭可能既不受理,也不收材料,还不出具书面意见。这无疑严重侵害了当事人接受裁判的权利,由此产生了一些消极的社会影响。”^⑱张卫平教授一方面认为普遍存在的法院依据其内部规定、文件等司法政策性规范对某些案件的起诉予以限制,“并非基于司法人员的不当动机,而是根据现实社会形势包括政治、经济等因素的考量所进行的限制,而且这种限制也有其根据,因而可以称之为‘合法性限制’。这里的‘合法’是从广义上讲的,因为这种限制不是依据法律、法规、司法解释的既有规定,而是基于相对‘隐性’的司法政策”。另一方面他又认为这一现象的存在“以牺牲法律和司法的权威性以及法律的普遍性为代价,不利于我国的法治建设”^⑲。而吴英姿教授更直斥为法院的“势利”。^⑳

其实,如果我们对20世纪80年代至今的司法史稍加考察,可以发现我国法院面对纠纷的受理呈现出一种前恭后倨的态度。从改革开放初期的积极扩张,到面对社会深层次矛盾日益显现的自我限缩,乃至出现所谓的“选择性司法”,这个过程非常值得深思!上述有的学者认为这是一种司法不作为,是司法进程的倒退,最起码也是路径的迷失。但在司法的应然已不是问题的前提下,如果不对法院在案件的受理上自我退缩的

⑭ 张维迎:《诉讼过程中的逆向选择及其解释——以契约纠纷的基层法院判决书为例的经验研究》,载《信息、信任与法律》,三联书店2003年版。

⑮ 贺欣:《运作不良的基层法院?》,载《法律和社会科学》(第一卷),法律出版社2006年版,第61页。

⑯ 参见前引⑥,贺欣文。

⑰ 汪庆华:《中国行政诉讼:多中心主义的司法》,载《中外法学》2007年第5期。

⑱ 前引①,段文波文。

⑲ 前引②,张卫平文。

⑳ 吴英姿:《司法的限度:在司法能动与司法克制之间》,载《法学研究》2009年第5期。

内在原因进行研究并进而对社会转型期司法角色有一个切合实际的把握,只是一味按照理想化的角色定位,可能并不切合当下实际。

二、通过立案审查的选择性司法:政治、社会与法律原因

选择性司法说白了反映的就是法院在当今社会发展阶段中的角色定位。敞开大门还是抬高门槛绝非法院本身一厢情愿,在“现代性袭来之时”是否一定会出现“难以处理的案件命中注定将会被排除在现代法院的大门之外”,我们不敢妄加判断,但当下中国的司法图景出现这样一幅选择性司法的场景则有其必然性。背后原因我以为大致有这三个方面:第一,司法不能解决因社会转型造成的利益调整、阶层分化而引发的所有矛盾纠纷;第二,司法的职能构造和角色安排很大程度上取决于制度设计者的现实需求与选择而非司法的自我定位;第三,司法的固有局限与纠纷的多元化解决定了司法必须克制。兹述之:

1. 司法不能解决因社会转型造成的利益调整、阶层分化而引发的所有矛盾纠纷

社会转型是当代中国的主题。其任务和目标也就是建设现代法治国家,或曰“良好法治下的文明秩序”。^①从大历史的视角看,这一历史进程从十九世纪末到今天已横跨三个世纪历时一百多年,至今尚未完成,整个中国依然处于一个巨大的社会转型过程中,唐德刚先生将其形象的比喻为“历史三峡”。^②“建设有中国特色的社会主义”和法治中国的实践已经描绘了完成转型的美好愿景。从当下看,改革开放三十多年来的历史又是社会变迁非常剧烈的时段,在这样的一个社会变迁期,我们的经济和经济体制正在逐步向市场化迈进,但适应这一市场化进程的政治体制、法律制度和其他社会体制还未能建立完善,由此带来当今中国社会的许多深层次问题。具体在社会结构与社会运行中至少呈现出以下三个特点:一是利益格局深刻调整,社会发展不平衡,社会矛盾特别是不同阶层之间的矛盾较为普遍,不同阶层和群体之间缺乏有效的扭合机制。二是支持经济正常发展和社会规范运作的资源配置不合理。典型者如一些利益集团对公共资源的鲸吞、国企的垄断、银行业的“嫌贫爱富”“媚大压小”、中小微企业资金的极度短缺等。三是社会规范缺失以及支持社会规范运作的资源条件不足,政府执行力薄弱,全社会诚信严重不足,社会各类纠纷突出,社会关系不稳定。

在这个大背景下,许多社会矛盾纠纷的产生有其特定的社会与历史原因。主体多元、利益连锁、历史包袱沉重、问题解决牵一发而动全身的特点非常明显。“许多表面上涉及法律争讼的纠纷,其中往往牵涉政治和其他社会因素,不是司法机关能够独立加以处理和解决”。^③或者说进入司法程序的个案貌似能够解决,但个案代表的诉讼之外的社

① 秦晓、金耀基等:《社会转型与现代性问题座谈纪要》,载《读书》2009年第7期。

② 朱正:《纪念唐德刚先生》,载《南方周末》2009年11月5日第27版。

③ 前引②,张卫平文。



会冲突法院力所不能及。故有学者指出:“将转型时期的社会矛盾相对集中地提交司法,中国司法的现实条件尚不足以保证司法承载这样的历史使命”^④。考察这些年来渐次爆发的带有普遍性的社会矛盾纠纷,可以发现很多是随着经济的发展,贫富悬殊的加剧,社会阶层的分化,而引起一部分群体心里不平、心理失衡引发。如其中上访问题最突出并进而引发系列民事、行政纠纷的改制企业下岗职工待遇问题、复转军人待遇问题、民办教师待遇问题、农村电工和电影放映员问题,等等,都不是权利直接受到了侵害,而是相关群体感到权利没有随着社会发展而提高,这是典型的社会发展引起的权利增长诉求。类似这样的纠纷更多的需要政策调整而非个案判决来解决,司法无力也不能制定这样的公共政策。再如涉农嫁女“承包地征收补偿费用分配纠纷”,最高法院对于此类纠纷受理与否或是不同部门打架,或是前后意见不一,全国法院则普遍持不受理态度。^⑤“农嫁女”纠纷问题本身因经济发展特别是城市化进程引起,总体上属当前我国社会转型时期的利益冲突和碰撞,它交集了产权制度、传统习俗、权利保障和社会稳定等诸多复杂的现实和历史因素,涉及土地资源有限性和成员资格开放性的矛盾,法律规定和村规民约矛盾,多数人利益和少数人利益的矛盾,也包括现实政治经济利益和社会长远发展方向的矛盾,等等。如果说有地方党委政府出台保护“农嫁女”合法权益的政策,法院同步尝试受理纠纷还比较顺利,不然则阻力重重。如浙江某市政府2008年曾出台《规范农村土地征用补偿费管理的若干意见》,试图对包括“农嫁女”问题在内的农村集体经济组织成员之间的相关问题予以详尽规定,但在试点过程中遭该市村集体和村民的强烈抵制,最终胎死腹中,法院开门受理后也随之被迫重新闭门。许多地方党委政府并不支持司法介入,因为推翻“村规民约”无疑会增加政府治理基层的成本,影响基层社会的稳定。而离开党委政府的支持,基层法院几乎难有作为,处理不慎甚至可能引发事与愿违的反弹和连锁反应,社会效果不好,同时损及司法公信和权威。这也是当时多数法院不敢轻易受理纠纷的一个重要原因。尽管2005年9月1日最高人民法院出台《关于审理涉及农村承包纠纷案件适用法律问题的解释》,规定涉农嫁女“承包地征收补偿费用分配纠纷”可以作为民事案件受理,但多数法院仍不敢轻易放开,此间主要涉及执行难和新老案件如何平衡、衔接的问题。有的曾一度放开但不久即重新关闭,其核心问题是判决遭到大部分村民的强烈抵制,有的案件所涉经济利益已经分光,村集体经济组织也无其他财产可供执行,判决成为一纸空文。

当法院希望自己作为公共权威力量之一在转型时期登上历史舞台,甚至一些法院

④ 蒋剑鸣等:《转型社会的司法:方法、制度与技术》,中国人民公安大学出版社2008年版,第12页。

⑤ 对于法院是否受理农村集体经济组织与其成员之间发生的收益分配纠纷,最高人民法院曾于1994年12月给江西省高级人民法院的答复中明确不属于法院受理案件的范围,当事人应向有关机关申请解决”。2001年7月最高人民法院研究室在给广东省高级人民法院的答复中出现反复,提出农村集体经济组织与其成员之间因收益分配产生的纠纷属平等民事主体之间的纠纷,当事人就该纠纷起诉的应当受理。”但2002年8月,最高人民法院立案庭在对浙江省高级人民法院所作答复中又指出对于因土地补偿费发生的争议和因安置补偿费产生争议但人员需要由农村集体经济组织安置的不予受理。

希望自己成为引导社会改革的前锋角色时,“司法”的对象是不是司法机关力所能及,确实是一个值得首先考量的问题。不要说司法难以承载起一些本不应当由其担负的责任,由于转型过程中的许多问题属于制度不完善或者发展中的问题,社会需要比较宽松的发展环境,许多问题看不清的尚需假以时日,对此更不适宜由法院通过司法程序匆匆作出简单的法律评判。法院只是确认规则,可以解决一些比较重大的、具有实际规则意义的案件。对于一些涉及政策性的甚至高度政治性的法律问题,现实条件并不适宜司法介入。1978年富勒教授在《哈佛法律评论》发表的《司法的形式与界限》就提出了有效司法的界限问题,讨论了什么样的社会事务适合司法处理,什么样的事务由司法解决可能无效因此应交由立法等其他部门处理。^⑤ 转型时期的中国应该说明显的体现出这一点。

2. 司法的职能构造很大程度上取决于制度设计者的现实需求与选择而非司法的自我定位

社会治理过程对司法的倚重,本是法治社会的应然。但我们如何理解与应对这样的倚重,确实不是我们想当然那样简单。法律制度可以建构,甚至可以采取拿来主义办法直接移植,但对法律制度合理与否的评介,却不能脱离文化的意蕴背景。^⑥ 因为“法律秩序是生长的”,它主要取决于社会内部的环境土壤,^⑦ 纵观世界各国的法治历程,大凡法治建设比较成功的国家,无一不是较好地坚持了法治规律与本国国情的创造性结合,实现法治原则的地域化。^⑧ 法律是多元的,作为建构在此基础之上的司法制度,我们当然只能从它所依存的历史传统和现实环境中加以理解和认识。^⑨ 正如美国著名人类学家吉尔兹所言,司法制度在凝聚人类文明共性智慧的同时,更是一种“地方性知识”。^⑩ 因此,“各国法院的设置、法院在国家架构中的地位与权重(纸面上与实践中)、法院与其他权力机构的互动中介或者机制,等等,均因各自的历史传统、政治文化、经济发展、法律文明、国家结构形式等具体国情的不同而呈现出差别”。^⑪

转型时期的中国法院其所处角色从表面反映出来的情形看,自身尚不具备解决各种社会矛盾和社会冲突的实力,直观上表现为需要处理的各种类型的案件超出了法院的负荷。其实,深层次的问题还与司法在我们国家的制度结构特别在制度实践中,以及在全社会的权威体系中的地位有关,换言之,这是由我国特定的政治架构所决定的。我国宪法中虽也明确人民法院依照法律规定独立行使审判权,然而,宪法所规定的审判权的“独立”行使当然不独立于执政党之外,我国人民法院是在中国共产党领导下依法独

⑤ 参见耿利航:《群体诉讼与司法局限性——与证券欺诈民事集团诉讼为例》,载《法学研究》2006年第3期。

⑥ 蒋大兴:《质疑法定资本制之改革》,载《中国法学》2015年第6期。

⑦ 刘金国、蒋立山:《中国社会转型与法律治理》,中国法制出版社2007年版,第49页。

⑧ 袁曙宏、韩春晖:《社会转型时期的法治发展规律研究》,载《法学研究》2006年第4期。

⑨ 彭小龙:《现代社会中司法的力量——兼论转型中国司法的两难困境及应对》,载《现代法学》2009年第6期。

⑩ [美] 吉尔兹:《地方性知识:从比较的观点看事实和法律》,邓正来译,载梁治平主编:《法律的文化解释》(增订本),三联书店1998年版。

⑪ 刘树德:《法院设置的宪法表达》,载《人民法院报》2013年11月22日第7版。

立行使审判权的,而不是实行“政治中立”、“司法独立”的司法机关。同时,人民代表大会制度是我国的根本政治制度,是人民法院赖以存在的根本制度平台。在人民代表大会制度下,“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督,这就从国家政体制度上明确了人民法院与同级人民代表大会的关系是从属关系,而不是彼此平行、相互制约的关系。人大可以通过院长及审判人员的任免,年度工作报告的审议,乃至个别问题的质询、甚至个案监督或对特定法官办案情况进行抽样监督等等方式行使监督权。^③ 党的十八大强调依法治国是党领导人民治理国家的基本方略,法治是治国理政的基本方式,由此,有学者撰文提出了加强法律制度建设将成为新一轮改革的突破口或重点任务。^④ 但司法体制改革必须在现行宪法框架内,并回应现实的政治生态。这次司改涉及的几个主要方面,包括法官员额制、审判责任制、法官职业保障以及省以下人财物统管等,主要是从对法官隆其地位、重其责任、厚其俸养以及减少地方党政对司法干预的角度,^⑤设计相应的机制改革项目;其没有也不可能涉及变动法院在现行国家机构中位置及相应的权力配置问题,地方各级党委仍将在思想上、政治上保持对地方各级法院的领导,法院院长仍将是地方党委政法委员会的成员。不管我们是否在一般意义上探讨国家权力架构中司法应该具有什么样的地位,甚或司法独立是否为实现司法公正并维护社会公平正义最佳甚至唯一的路径。^⑥ 但是今天我们探讨的是在这一现实框架内的司法角色及法院应何作为。正如有学者指出,司法本质上是作为政权主体中的一部分来运作的,无论是权力制衡、纠纷解决还是其他,司法的构造很大程度上取决于制度设计者的需求与选择。^⑦ 有的学者论及法院地位似乎美国三权分立、司法独立是唯一参照,实际上这样的模式也只是其中之一。我们并不能以个别现象来解释普遍现象。^⑧ 譬如法国,由于法院“在大革命中属于败方,其后失去了大量权力和威信,直至今日,法国是否信奉司法机构应该独立于其他政府部门的原则依然值得怀疑。法院不以抗衡其他政府机构官员的行为而出名,没有人指望法院在统治国家方面起积极作用。”^⑨ 所以,在司法尚不具有这一地位的前提下,一味主张法院不能拒绝受理所有案件可能只是乌托邦式的幻想。我们的治理体制当然已经不是“行政兼理司法”,甚至司法就是政务。^⑩ 但在整个政治架构中,司法还处于一个相对较低的位置。^⑪ 某种程度上法院实际还只是一个处理纠纷解

③ 有学者称:围绕法官形成的监督机制和监督力量已经让法官们喘不过气来。参见凌斌:《法官如何说理:中国经验与普遍原理》,载《中国法学》2015年第5期。

④ 刘树成:《新一轮改革的突破口》,载《人民日报》2013年6月13日。

⑤ 长期以来,地方法院一直不具备抵御地方党政干预的能力。参见王建学:《地方各级人民法院宪法地位的规范分析》,载《法学研究》2015年第4期。

⑥ 参阅信春鹰:《中国需要什么样的司法权力》,载《环球法律评论》2002年春季号。

⑦ 前引②,袁曙宏、韩春晖文。

⑧ 参见[英]休谟:《休谟政治论文选》,张若衡译,商务印书馆2012年版,第62页。

⑨ 前引②,刘树德文。

⑩ 里赞:《司法或政务:清代州县诉讼中的审断问题》,载《法学研究》2009年第5期。

⑪ 前引③,凌斌文。



决的机关,法官还不可能摆脱这样的角色安排。^④

必须指出的是,认为任何一个纠纷都可以诉诸诉讼,法院不能拒绝收案、拒绝审判,其蕴含的前提就是司法是公平正义的最后一道防线,任何纠纷应该“司法最终解决”。但在现实生活中,我国司法并非对任何纠纷案件都能成为“最后一道防线”,司法是公平正义的最后一道防线其实应该是公众对司法应然功能的一种期待。我国不实行西方的三权分立政治制度,不实行西方司法独立和司法至上的政治原则,没有普通法院违宪审查制度或者宪法法院的合宪性审查制度。因此,在什么情况下司法才能成为“最后一道防线”,需要从我国国情和实际出发,做出实事求是的分析和把握。司法作为实现社会公平正义的最后一道防线,其主要职能是通过矫正正义使偏离法律轨道的法定公平正义得到回归,而要成为最后一道防线意义上的司法诉讼案件,必须符合法院受理案件的范围和条件。立法通过分配正义将社会成员公平正义的某些诉求法律化,可以说是实现社会公平正义的第一道防线;行政通过执行正义将法律化的社会公平正义付诸实施,可以说是实现社会公平正义的第二道防线。换言之,如果社会成员公平正义的诉求尚未通过立法程序转化为法律诉求,成为法律可以具体维护和保障的公平正义,司法对于这种“公平正义”往往是爱莫能助的。本文前述社会转型期的许多矛盾纠纷为什么法院往往感觉束手无策,其实问题的关节点就在于它往往尚未被纳入法律的范畴,不是通过诉讼程序能够解决,尽管它们对于每个当事公民来说都是非常重要的“社会公平正义”问题,因而法院的最后一道防线对于这些非法律问题可以说是鞭长莫及。我们以社会自治组织内部纠纷——农村基层选举纠纷司法救济的可行性为例稍作展开。我国自1988年试行村委会直接选举以来,经过20多年的运行,选举日渐常态化。截至目前,中国共有58.9万个村委会,其中有98%以上都是实行直接选举,村民平均参选率达到了95%以上。^⑤在这个过程中,一方面由于取消各项农业税费,乡镇政府已大大弱化对村委会选举的组织、监督;另一方面,由于“村官”不再负责税费征收,选举吸引了更多农村精英加入,竞争性逐步提高;在一些地方,村委会因掌握巨额集体资产,“贿选”问题日渐显现。由此一些学者建议在《村民委员会组织法》修订中增加选举争议的司法救济机制,如果村民对选举过程存在的贿选等舞弊行为提出异议,由法院受理并审查选举违法行为。但在2010年10月28日新的《村民委员会组织法》中,全国人大并未支持这一建议。理由首先在于村委会是一个社会自治组织,司法能否介入其内部事务理论上存在极大的争议。其次最易引起选举纠纷的所谓“贿选”问题难以界定,例如乡土社会中的请客送礼能否认定为贿选,承诺当选后给乡亲的福利待遇回报如何定性,家族乃至宗祠在选举中的号召与操作怎样处理,等等,都很难从司法的层面给予判定。中纪委、中组部、民政部在2006年曾专门下发《关于认真解决村级组织换届选举中“贿选”问题的通知》,但对最为关键的“贿选”并未给出界定。至于法院案多人少、一旦成讼将给整个法

^④ 前引②,张卫平文。

^⑤ 人民网2013年3月13日。



院系统带来巨大压力当然也是考量因素。这一问题实际上与涉农村集体经济组织成员权益纠纷,特别是农嫁女权益保障问题异曲同工。确认享有集体经济组织成员权益需以具备成员资格为前提,而成员资格的认定涉及身份归属。迄今全国人大未在相关立法中予以明确,全国人大法工委在针对全国人大代表要求就集体经济组织成员资格界定标准作出解释的建议答复中称:农村集体组织成员资格的认定比较复杂,需要综合考虑当时的政策、村集体组织的土地来源、构成、变迁,以及其有无在本村集体经济组织内从事过劳动、时间长短、贡献大小等因素;为了达到较好的社会效果,可在当地人民政府的指导下,根据本村、本地实际情况,由其所在村的村集体经济组织依照法定程序予以认定。由于这类纠纷的产生几乎都是因为村集体经济组织排除涉纠纷当事人的主体资格而引起,上述答复,显然排除了司法对此的救济,其原因在答复所描述的问题的复杂性中已阐述的一览无遗。终点回到起点,司法难有着力之处。

全面实现社会公平正义有赖于国家和社会治理的系统工程。所谓法律的归法律,政策的归政策,道德的归道德,司法不可能包打公平正义的天下。我们应当从中国特色社会主义民主政治和初级阶段的基本国情出发,对司法实事求是地做出功能定位,赋予它能够承担和实现的功能。^④ 如果已经证明中国的许多问题是现阶段的司法不能有效解决,而别的途径更为有效,无论在理论上还是实践中都应减轻司法的难以承受之重。

3. 司法的固有局限与纠纷的多元化解决定了司法必须克制

纠纷是社会主体之间的一种利益对抗状态,蕴含着对现存秩序的破坏。但是社会需要秩序,否则便将消散和瓦解。由于纠纷的发生是必然的,如何科学、有效、彻底地解决纠纷也就成为必然选择。纠纷的发生和解决构成了人类社会发展的—对永恒的矛盾,也正是在解决这对矛盾的过程中人类社会不断趋于进步。设置法院的目的或作用主要就在于定纷止争,那么为什么说司法又只能是各种解决纠纷机制中的一种呢?

司法的固有局限首先决定了司法必须克制。任何一种权力都有它的效力边界,司法在当今社会扮演的角色尽管因各国的国情不同而不同,但其并非无所不能。在西方,特别在英美法系,司法权的边界在宏观层面上被置于三权分立的框架中,划分司法权与立法权、行政权的界限。微观层面则表现为案件的可裁判性和法官释法的空间,即司法的能动性及限度。^⑤ 由于司法权与行政权的不同特性,相对于急剧变动的现代社会日益复杂、多样的纠纷,这两类公权的权力版图本身也在不断的消长之中。特别是历史进入20世纪以后,政府日益走出“守夜人”的藩篱,行政权逐渐扩大,因此18世纪传统意义上的三权分立日渐不再。由于行政权的不断扩张,行政机关同时拥有了部分立法权和

^④ 李林教授对中国特色社会主义初级阶段司法的功能定位就提出了自己的独特看法。参见《慎用“司法是实现公平正义最后一道防线”这一提法》,载《北京日报》2008年5月5日。

^⑤ 参见前引^④,贺欣文。

司法权,一定意义上也已打破传统的分权原则。^{④6} 在面对一些特殊纠纷时,以传统意义上的三权分立框定司法权限已经难以适用。例如,企业破产案件应该是法院传统的势力范围,但在当下比较普遍的涉及金融机构破产重整的案件中,制度安排往往要求法院让渡或者说收缩自己的权力,这不独在我国,其他国家也不鲜见。尤其在特别强调程序正义、三权分立的美国,由行政监管当局负责主持金融机构的破产程序,排除普通破产法的适用或者规定优先适用特别行政程序法,其间行政权力一家独大,司法权力的空间被极大的抑制。^{④7} 制度之所以做如此安排,就是由金融机构的特殊性质决定的,而这种特殊性恰恰是在金融机构经营失败出现危机时才得以集中体现。个别银行的倒闭,其危机会因为民众理性或非理性的判断而传染到整个银行业,并导致整个经济体的系统性风险突然升高,进而直接损害实体经济的稳定。因此一家银行的市场退出过程并不是简单的个体行为,而势必要转化为公共事件。在这一过程中,很有可能甚至必然触及如何预防、控制和消除金融市场的系统性风险以及避免个别银行的问题演变为整个金融市场的灾难,任何一个政府的首要目标无疑是迅速减少系统性金融风险发生的概率或者是降低系统性风险发生后对市场和社会造成的损害,保护整体金融市场的稳定。此间,以被动、居中、注重保护个体利益的司法显然力有不逮。如果说上述金融机构破产仅仅属于个案或者说只是域外的例子,那么前些年对于当时非常敏感的群体纠纷、公益诉讼、社会自治组织内部纠纷等,即所谓“涉及面广、敏感性强、社会关注度高”的纠纷案件,司法是否有能力全部介入却不是想当然就能作出肯定的回答。有学者就认为:司法通过解决纠纷实现其社会控制功能,如果说处理发生在私权利领域的单纯利益纠纷是司法所擅长,那么如果涉及目前非常敏感的群体纠纷、公益诉讼、社会自治组织内部纠纷等,司法机能的有限性就会显露出来。^{④8} 应该说,无论从当事人的角度认为立案难也好,还是从法院的角度认为需要设置门槛也好,问题往往集中在此。

同时,诉讼解决纠纷在其方式上也有其固有缺陷。法律程序“是一种恢复、维护或创造社会秩序的介于道德和武力之间的特殊程序”,“是被发明出来应付潜在的或实际的对社会行为规范或模式的干扰”。^{④9} 而民事诉讼程序又“是以保护主体权利、解决纠

^{④6} 如在美国,行政机关拥有立法权(颁布具有法律效率的规章之权)已经司空见惯;自1914年开始美国联邦贸易委员会就具有了对商业种不公平竞争案件裁决的司法权力;而1969年纽约州颁布了机动车辆和交通法,把一部分违反交通规则的非罪,由法院移交行政机关审理。在英国,行政权兼领立法权的态势突出表现为进入福利国家后委任立法数量的急剧增加;行政权兼领司法权的态势则突出表现为行政裁判所的大量设立。参见前引②9,袁曙宏、韩春晖文。

^{④7} 在银行破产领域,美国联邦存款保险公司(FDIC)被赋予了相当宽泛的权力。它不仅具有完全排他的启动破产程序的权力,而且在破产程序中它既作为银行的接管人,同时在向存款人偿付了保险金后,他又成为银行最大债权人。FDIC在接管银行后,承担了该银行股东、成员、存款人、管理人员和董事所有关于银行及其资产的权利、头衔、权力和特权。它被授予广泛的权力去处置银行的资产以使其恢复经营能力,例如可以促成与其他银行合并,出售资产和债务,或者设立一家过桥银行去承担这家失败银行的资产和债务……FDIC所主导的这些交易无需其他任何机构、法院、合同权利当事人或者银行股东的同意,从而便于其以最快的速度 and 最低的成本处置失败银行。参见黄韬:《我国金融机构市场退出法律机制中的权力版图》,载《中外法学》2009年第6期。

^{④8} 前引①5,贺欣文。

^{④9} 吕世伦主编:《当代西方理论法学研究》,中国人民大学出版社1997年版,第271页。

纷和维护私法秩序为设立宗旨”,“其内含的程序公正和程序效益的价值目标能够保证程序主体以最经济的方式实现自己的民事权益”。^⑤但是,对于纠纷的解决方式而言,诉讼程序又有其固有的缺陷和弊端,就民事诉讼而言:它是一种极具职业专门性的活动,在认知方面不易为一般民众所理解和接受;与其他民事解决纠纷机制相比,程序复杂繁琐、时间持久、成本高昂;其严格规范性和国家强制力,在很大程度上限制了当事人的意思自治,从而难以适应特殊个案所需的灵活性解决要求,也难以满足当事人之间不伤和气与维持原有关系的要求。

上帝关上一扇门,同时打开一扇窗。司法鞭长莫及力有不逮之处,正是多元化解纠纷机制长袖善舞能够着力之地。多元化解纠纷机制应成为解司法围城之困的不二选择。日本学者棚濑孝雄把解决纠纷机制分为根据合意的纠纷解决方式和根据决定的纠纷解决方式。前者指双方当事人就以何种方式和内容来解决纠纷等要点达成合意而使纠纷得到解决,其典型是调解;后者指第三者就纠纷应当如何解决作出一定的指示并据此终结纠纷,其典型是审判。^⑥美国学者埃尔曼也将解决纠纷的方法归为两类:(1)纠纷主体通过协商,自己来确定解决结果,其间不排除第三人作为调解人在协商中予以协助。(2)将纠纷交付裁决,由一位不偏不倚的第三人来决定哪方优胜。埃尔曼认为,这两种方法可用以(有时相互交叉)解决民事、刑事和行政纠纷,在缺乏裁决机构的地方或者蔑视诉讼的地方,通过协商解决纠纷是人们倾向性的选择。^⑦一个稳定的社会,仅仅依靠司法系统解决纠纷是远远不够的,而是必须建立一套以非诉解决方式包括调解、仲裁为中心、以其他解决方式补充、以诉讼解决为终极环节,适应不同需求的多元化纠纷解决体制。在这个机制中,各种解纷方式既相对独立、又互相配合,从而在宏观上适应社会变迁需要,解决民事纠纷,保障交易安全,维系社会秩序;在微观层面减轻法院负担,使普通民众能够方便、迅捷的“接受正义”。目前,世界上把法院以外的各种非诉讼纠纷解决方式统称为代替性纠纷解决方式(ADR)。随着代替性纠纷解决方式在现代社会中被广泛大量地应用,其功能和地位也日益提高,形成了与民事诉讼机制相互衔接的多元化纠纷解决机制。开发利用代替性纠纷解决方式与改革民事诉讼制度已成为现代司法改革中相辅相成的两个方面。

基于司法的固有局限和诉讼的内在缺陷,就法院而言,不能自己把司法神圣化,只看到诉讼程序的价值所在;就当事人而言,同样不能膜拜司法,而应请下神坛看到司法永远只是各种纠纷解决机制中的一种,在遇到纠纷需要保护自己利益的时候无需被迫选择诉讼;就社会而言,建设法治国家,建立一个高效、有序的社会治理体制,必须健全各种纠纷解决机制。从总体上要让各种纠纷解决机制既相互竞争,又互相补充。转型时期深层次矛盾凸显、各类纠纷频发的当今中国社会,树立这样的平衡观念更显必需且

⑤ 肖建国:《民事诉讼程序价值论》,中国人民大学出版社2000年版,第364-365页。

⑥ 参见[日]棚濑孝雄:《纠纷的解决与审判制度》,王亚新译,中国政法大学出版社1994年版,第2-3页以及第7-15页。

⑦ 参见[美]埃尔曼:《比较法律文化》,贺卫方、高鸿钧译,清华大学出版社2002年版,第155页。

迫切。如果历史已经证明转型社会大量矛盾纠纷袭来时司法的独木难擎,我们必须让多元的纠纷解决机制共同撑起这片天空。

三、从立案审查到立案登记:转身后的回应

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确改革法院案件受理制度,变立案审查制为立案登记制,其出发点在于保障当事人诉权,对人民法院依法应该受理的案件,做到有案必立、有诉必理。可以说以立案登记制取代立案审查制,表层意义首先体现为人民法院在立案程序上已从职权模式转向诉权保障模式,更深层的意义在于法院的司法角色或说职能应该有一个很大的变化。但是,撇开法院从“最后一道防线”突进为没有前沿掩体的纠纷受理机构,案件井喷、案多人少矛盾进一步加剧不论,在法院通过立案审查制采取选择性司法的三大因素仍然存在,即:司法解决因社会转型造成的利益调整、阶层分化而引发的矛盾纠纷能力不足,司法的职能构造和角色安排没有变化,司法固有局限与纠纷多元化解仍然决定了司法必须克制的前提下,或者说在我国社会仍将处于较长时期的社会转型过程这一大背景下,如何实行立案登记制并妥然应对由此而来的司法环境的改变,这对现阶段的法院和法官都是极大的考验。其间,有几个问题必须解决:

1. 受理“依法应该受理的案件”:立案过程中登记与审查的关系

变立案审查制为立案登记制,强调“有案必立、有诉必理”,社会普遍有一种法院应该敞开大门解决所有纠纷,对于起诉应该登记后即转化为法院审理的案件,不应再经任何审查的期待。即所谓“有案就立,立案即审”。如何回应这种期待,把握好起诉与受理、登记与审查、诉案与可审案之间的关系,这是实行立案登记制后必须首先解决的问题。

第一,纠纷不因“诉”而当然进入审理程序,对其进行甄别审查是法院立案程序的固有内容。

立案审查制向立案登记制转型,是一次受案条件“瘦身化”改革。^⑤ 它并非否定法院的审查功能,也不是降低法院可审理案件条件,更不是将立案程序简化为单一的登记手续,而是要求在立案程序中实现诉权与职权之间的平衡。域外实行立案登记制的大致有两种模式:绝对模式和相对模式。但无论何种模式,登记中的审查都是必经程序。如采用绝对模式的法国,尽管一般情形下登记即等同于立案并直接进入诉讼程序,但其在现行《行政诉讼法典》中用十六个条文对起诉状的提交要求进行规定,不符要求的不予受理。采用相对模式的如德国、日本,规定经法院对原告的起诉内容、当事人是否明确等进行审查,起诉程序才告完成。日本《民事诉讼法》沿袭德国模式,规定原告向法院起诉后,法院根据事务分配规定分配给特定的法官或者合议庭,由该法官或合议庭审判

^⑤ 参见前引①,段文波文。

长对诉状进行检查,并就是否缺乏必要的事项记载等进行审查。^{⑤4}我国实行的立案登记制类似于相对模式,主要解决在受案范围内应该依法立案而不予立案,以及实践中因法外因素(如政策)故意规避不接收材料、不出具不予立案裁定等问题。按照新行政诉讼法,立案登记时围绕提起诉讼的法定条件进行审查,包括审查诉状的内容是否完整、是否符合起诉状形式等。^{⑤5}

第二,“有案必立、有诉必理”的前提是“依法应该受理的案件”,如何将“依法应该受理的案件”与“不该受理的案件”区别开来,需要通过审查才能认定。

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》对此的完整表述是:“改革法院案件受理制度,变立案审查制为立案登记制,对人民法院依法应该受理的案件,做到有案必立、有诉必理,保障当事人诉权”。何谓依法应该受理的案件,除了纠纷必须符合一些必要的诉讼程序条件外,其实更主要的是还从政治的、社会的等因素加以考量。社会纠纷复杂多样,有些具备法律意义及审理价值,可通过诉讼予以解决;有些不具备法律意义及审理价值,不能通过诉讼解决;有些因司法固有局限或阶段性的尚不具备解决能力,难以通过诉讼解决。法院不是包揽社会所有纠纷解决的解纷机构。因此,纠纷成“诉”至法院,是否具有可诉性,能否转变为诉讼程序意义上的案件,需要法院在立案中对“诉”请背后的纠纷进行审查,将当事人提起的“诉案”与法院的“可审案”区别开来,将那些达不到法律条件的纠纷排除在法院之外。就此而言,法院的立案审查功能,是与纠纷的可司法性相伴相生的天然性功能,是保障法院顺利行使职权的必备功能,无论立案审查制还是立案登记制都不可或缺。

第三,符合登记要件而被登记立案的是否符合审理要件并进入实体审理程序尚需审查。

登记要件包括诉状符合法定形式、当事人出具有效身份证件、缴纳诉讼费用。审理要件是指法院对本案实体权利义务争议问题继续进行审理并做出实体判决的要件。^{⑤6}基于诉状登记而立的案件,只是具备了初步的案件形式,而非具备审理要件的实质案件。只有具备了审理要件,案件才是真正意义上的受案法院可审案件。在美国,限制联邦法院受理事项范围的审理要件为:必须具备宪法第三条意义内的案件或争议;原告必须具备诉讼资格(Standing);案件必须是成熟的(Ripe);案件不能是已失去实际意义的;案件不能构成政治问题。这些要件通常也被称为可裁判性(Justiciability)原则。^{⑤7}在日本,审理要件包括:法院对案件一般具有审判权和管辖权;当事人必须具备相应诉

^{⑤4} 参见江必新、梁风云:《新行政诉讼法司法解释理解与适用》,中国法制出版社2015年版,第5-8页。

^{⑤5} 张文忠:《〈新行政诉讼法〉实施与法院立案登记制度》,载《上海审判实践》2015年第3期。

^{⑤6} 参见[日]新堂幸司:《民事诉讼法》弘文堂1989年版,第203页;[日]高桥宏志:《重点讲义民事诉讼法》(下册),有斐阁2004年版,第1页。转引自张卫平:《起诉条件与实体判决条件》,载《法学研究》2004年第6期。

^{⑤7} [美]海利·爱德华兹等:《美国联邦法院的权力和法院命令的执行》,转引自宋冰主编:《程序、正义与现代化:外国法学家在华演讲录》,中国政法大学出版社1998年版,第212页。

讼能力;诉讼标的必须是特定的,当事人要有诉的利益等。”^⑤可以看出,所谓审理要件主要包括三个方面,一是法院的审理资格,比如管辖等;二是当事人的诉讼能力;三是诉讼标的即权利的可诉。不具备审理要件,实际上就意味这个案件并非真正意义上的法律案件,或是属于不适宜审理的案件,即便已登记立案,亦因法院无法审理而无实际意义。因此,对审理要件的审查,不同于登记要件的审查,其需要对相关条件进行实质化的审查,在这一点上,立案登记制与立案审查制并无根本区别。当然,我国的法律中未明确使用审理要件这一术语,而只是规定了“起诉应当符合的条件”。这一表述容易让人产生误解,即认为起诉必须符合的条件就是立案必须符合的条件,有学者也早已提出了不应将起诉条件作为立案条件^⑥。在实行立案登记制后,最高院立案登记制改革课题组提出了“登记要件”这一概念,以区别“起诉应当符合的条件”^⑦。

2. 确立司法有限的理念,明确受案范围的负面清单

如何处理好既保障当事人诉权,有案必立、有诉必理,又依法受理人民法院应该受理的案件的案件的关系,其中,是否应该、如何确定不予登记立案的案件范围,又最为敏感,也可以说极大的考验着最高人民法院的政治智慧和司法智慧。如果我们承认社会转型时期将社会矛盾纠纷相对集中地提交司法,中国司法的现实条件尚不足以保证承载这样的历史使命;承认司法有其固有的局限,其权力的边界受制于诸多客观因素;承认多元化解的解纷机制决定了司法不是解决纠纷的唯一渠道,那么明确权力清单,合理划定受案范围,是一个合乎逻辑、与保障诉权并不矛盾的必然选择,这也是司法权良性运行的关键。盲目地、不切实际地扩张受案范围,“有案就立,立案即审”,受理超出法院审理能力的案件,不仅纠纷得不到及时有效的解决,更会严重损害法院的司法公信和司法权威。应该指出,当前我国社会有一个非常明显的悖论:民众会对法院、对司法的需求越来越多,但对司法的不信任感也越来越大,“部分群众对司法的不信任感正在逐步泛化成普通的社会心理”。^⑧从彭宇案到聂树斌案等负面的影响性诉讼层出不穷,一些大法官相继落马,法院公正司法的能力一次次遭受严峻的拷问,以致“民众对司法的不信任几成思维定式”。^⑨问题的成因尽管十分复杂,但我以为至少包括以下几点:第一,司法端口是社会矛盾纠纷的最终集聚地,很容易成为民众发泄心中不满和怨恨的一个终端;第二,一些政府部门出现权力与资本、权力与既得利益集团捆绑在一起的现象,政府威信不同程度地消解,法院也难独善其身;第三,法官系普通公职人员,与英美法系法官、也与大陆法系法官的地位和权威度存在着很大差距;第四,法官腐败人数虽少但杀伤力极大;第五,一些案件处理不公、不当,通过网络传播放大,不断给公众造成负面影响;第六,权利救济体系的混乱,侵蚀司法机关的权威。重塑司法公信可以说是本届最高法院

⑤ 姜启波、李玉林:《案件受理》,人民法院出版社2008年版,第86页。

⑥ 参见张卫平:《起诉条件与实体判决条件》,载《法学研究》2004年第6期。

⑦ 最高人民法院立案登记制改革课题组:《立案登记制改革问题研究》,载《人民司法》2015年第9期。

⑧ 吴兢:《追求看得见的公正》,载《人民法院报》2009年8月19日。

⑨ 曾实:《公众质疑“撞车司机非替身” 学者:公众对司法不信任》,载《联合早报》2012年5月30日。

所要重点解决的问题,但超出法院能力的“有案就立、立案即审”绝不是一个好的选择。依法受理应该受理的纠纷,公开公正审理好每一个案件,让人民群众从中感受到公平正义,对于当下的法院更为必需和迫切。

对此,我们注意到最高人民法院《人民司法》刊登的《实行立案登记制,依法保障当事人诉权》一文。该文在对民事诉讼法司法解释进行全面解读的基础上,在“关于特殊类型民事起诉登记问题”一节中专门论及:“立案登记后,涉及政治、历史遗留政策、社会突发、热点敏感案件的起诉,无法回避。有针对国家领导人等政治人物、特殊党政单位的起诉等;有特殊主体提起的具有政治目的起诉,如国际组织提起的具有政治目的起诉;有诉讼内容涉及破坏国家民族、宗教、国防、外交等政策的起诉,如针对国家宗教、民主政策等基本政治制度的起诉等。政治敏感类案件,有涉及国家重大政策调整或历史遗留问题等的起诉,如对国家经租房、国有企业职工下岗等群体性的起诉。社会热点、突发敏感类案件,有涉及国家网监管理行为的案件,如对攻击党和国家社会制度信息的删帖、关闭网站等起诉,如对群体性事件的处置等起诉。这些起诉,如果简单立案登记,极易造成负面政治影响,容易形成连锁反应,影响国家社会安定。人民法院要积极依靠党委政府做好矛盾化解工作。对于不属于民事诉讼范围的,不予登记立案;属于人民法院民事起诉范围的,应当登记立案,依法判决。”^③笔者理解,上述涉及政治、历史遗留政策、社会突发、热点敏感案件的起诉,既然简单立案登记,极易造成负面政治影响,容易形成连锁反应,影响国家社会安定,这就决定了法院不能或不宜审理。因此,在民事诉讼以及行政诉讼中其大部分甚至全部都应列入不在法院受案范围之内,不予登记立案,或者裁定不予受理。

当然,最高人民法院《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》专门强调:禁止在法律规定之外设定受理条件,全面清理和废止不符合法律规定的两“土政策”。这是一个经中央深改组审议通过的规范性文件,上述由各省高院甚至中基层法院自行制定出台有关案件不予立案的意见的现象自在禁止之列。对于那些现阶段不属于法院受理案件范围不予登记立案的纠纷,应由最高人民法院以司法解释的明确规定,实行“非禁止即登记”原则,如果起诉所涉纠纷属于不予受理范围的,即可驳回诉状,不予登记,并列明当事人所诉事项属于何种不予受理的范围。至于规定方式,《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》第二条有不予登记立案的四种情形:(一)违法起诉或者不符合法定起诉条件的;(二)诉讼已经终结的;(三)涉及危害国家主权和领土完整、危害国家安全、破坏国家统一和民族团结、破坏国家宗教政策的;(四)其他不属于人民法院主管的所诉事项。不予受理的具体纠纷类型,笔者以为可以此为据细化明确。

3. 倡导纠纷多元化解,尽快建立诉前强制调解程序

基于案件高速增长带来的案多人少的极大压力和纠纷多元化解的需要,近年来各级法院通过诉讼服务中心这一平台将大量纠纷案件分流到非诉讼程序,在诉前及时、有

^③ 包剑平:《实行立案登记制,依法保障当事人诉权》,载《人民司法》2015年第11期。



效地化解纠纷,效果十分明显。但立案登记制实施后的实践表明,由于缺乏相应的配套法律及司法解释跟进,立案登记制的实行对纠纷多元化解乃至司法改革本身带来很大冲击,主要表现在两个方面:一方面,由于立案登记制便利、快捷和低门槛的特点,辅之以意识形态化的论证和宣传,强调对诉讼不加限制和制约,从而影响公众的诉讼观和当事人的选择,激发好讼心理,通过非诉讼程序解决纠纷的优势、功能和价值(协商、平和、双赢等)被舍弃或忽略。立案登记制实行后出现的当事人拒绝法院对纠纷的分流引导,案件量特别是民事案件大幅攀升的现象非常直观的反映了这一问题。例如,近年来案件数量庞大的物业公司催缴业主欠费诉讼,很多法院为避免不良社会反应,曾采取限制起诉数量或要求先行调解的方法应对。但立案登记制实施后,物业公司通过委托律师直接批量起诉,法院的分流引导功能受到极大限制,如采用既往做法又将承受“立案难”的莫大压力,导致诉前调解无法启动。类似纠纷在我们认为立案登记制使“老百姓起诉”更便利的同时,大企业特别是公用服务企业大批量向用户或消费者索债并由律师代理,“起诉老百姓”也将更加便利,并可能出现司法资源被大企业滥用的现象。另一方面,本轮司法改革具体路径之一是通过建立法官额制和以审判为核心的诉讼模式,提高法官的地位及其在审判中的独立性,逐步改变传统的低端司法和大众司法格局。实现这一目标,必须以纠纷的适度社会化和促进非诉讼解纷机制为前提和基础,促进更多的纠纷在法院外或诉讼外得到解决,将优质司法资源用于真正具有法律意义或非诉讼程序无法解决的案件上。但与西方国家将琐碎细小民事纠纷交非职业法官、通过非讼程序处理,普通程序按部就班的普遍做法不同,我国民事诉讼制度的传统就是效率优先,甚至更多的充满了功利主义色彩,强调无诉讼门槛、设置审限、考核结案率和未结案率、简化程序等等。所以尽管面对汹涌而来的纠纷法院以往通过立案审查过滤案件,但无论制度层面还是实践层面都以司法便民措施的不断加码、案件数量的不断增加为政治正确,每个法院一年一度的工作报告也都以此为向人大标榜的主要业绩。立案登记制的实施,更是强化了这一取向。在不断强化民众对国家权力和诉讼的依赖,耗费大量司法资源的同时,不断攀升的案件数量必将继续增加法院案件压力,案多人少矛盾下法官很难摆脱“司法农民工”的窘境。

正因为如此,2015年4月9日,最高人民法院院长周强在四川眉山全国法院多元化纠纷解决机制改革工作推进会上将多元解纷机制称之为“立案登记制的配套措施”,并强调要树立“国家主导、司法推动、社会参与、多元并举、法治保障”的现代纠纷解决理念。当然,由法院一家唱主角甚至独角戏恰恰违背了纠纷多元化解的本来意义,这一制度的本意就需要国家主导,以立法的形式确立和保障非诉讼程序的正当性,通过包括司法行政部门在内的多部门的配合发挥其作用。具体方式可以是:(1)建立法定前置调解制度,将部分不适宜直接通过诉讼程序处理的纠纷,如家事纠纷、相邻纠纷、小额债务纠纷、劳务纠纷、物业纠纷等剥离出来,由社会或法院附设的调解机构先行调解,调解不成再行诉讼。(2)建立专门的特定类型纠纷行政或准司法解决程序,将劳动争议、交通事故赔偿、医疗赔偿、消费者权益保护等纠纷整体性交付行政或准司法机构通过专门程序



处理,不进入普通民事诉讼程序,法院仅保留终局性司法审查和救济权。(3)改造小额诉讼程序,将该程序调整为非诉讼程序或者与前置调解整合,对所涉纠纷主要包括可以通过速裁一审终审的案件,由专业调解员、仲裁员或法院辅助人员特别是司改后的法官助理通过“调解+裁决”的模式处理。

4. 当事人诉权不当行使特别是滥诉的规制与防范

滥诉,某种程度上可说是诉讼门槛不断降低的伴生物。如韩国,近年来滥诉已成为社会一大突出现象。2011年全韩提起诉讼的案件中,被法院按照不起诉处理的竟占70.8%,其中,本意为方便大众的电子诉讼制度无形中更助涨了韩国的诉讼过度现象。^④立案登记制的实行使立案门槛大大降低,但当事人滥用诉权也因此成为困扰人民法院的一个非常突出的问题。特别在行政诉讼中,一些信访老户通过申请政府信息公开、申请履行法定职责等方式提起诉讼、重启诉讼的现象非常普遍。对于滥诉的规制和防范已成为立案登记制实施以后一个必须认真面对并解决的问题。如杭州有一对夫妇向各级政府及相关部门提出政府信息公开申请420余份,因此而申请行政复议63次,并就此陆续提起行政诉讼。又如上海部分老上访户通过信息公开、行政赔偿、行政复议等方式,提起大量行政诉讼案件,某区法院受理姚某诉该区住房保障和房屋管理局、区人民政府不服信息公开案38件,占该区法院同期受理的行政案件总数32.76%。

此类行政诉讼当事人往往以申请政府信息公开及相关复议诉讼为手段,利用行政复议及诉讼程序与政府纠缠;在审判过程中则滥用回避申请权,反复纠缠行政机关执法人员和出庭人员身份等问题,同时故意拖延诉讼进程,导致案件处理的难度增大,进而反复缠诉、投诉、申诉。起诉人通过滥用诉权甚至恶意诉讼,意欲对被告泄愤、报复社会的心态十分明显,司法和纠纷解决的效益往往被弃之不顾。^⑤其特点:一是申请主体密切相关,多为亲属、同事、同一集体经济组织成员等,有的甚至人为制造群体性诉讼。二是申请数量众多且多有重复,一个申请主体动辄提出几十件、上百件政府信息,或关联主体对同一或同类信息分别提出申请。三是申请内容五花八门,许多明显不属于政府信息的事项。四是申请理由多种多样,而背后往往裹挟着泄愤、报复、施压等真实动机。五是恣意穷尽救济程序,无论行政机关是否满足其获取和知悉政府信息的主张,均逐一提起行政复议和行政诉讼。上述杭州、上海的案例都具备这些特点。

起诉权是为实体权利提供保障的一项请求救济的程序性权利,这一权利的存在是为了保障实体权利的需要,其行使的必要性和正当性是正当程序原则的基本要求,其本身排斥反复提起轻率的、相同的或者类似的诉讼请求。滥诉不仅造成无辜被告精神上的和物质上的损失,更将耗费司法机关大量人力物力,导致巨大的社会支出。美国著名的公法学家霍尔姆斯和桑斯坦教授在《权利的成本——为什么自由依赖于税》中就指出:“没有运作良好的司法在财政上是独立的,没有法院体系能在预算的真空中运转”;“既

④ 《“先起诉再说”渐成社会风气,韩总理牵头应对诉讼过的现象》,载《法制日报》2012年5月8日。

⑤ 吴宏:《倡导理性诉讼—谨防陷入“滥诉”》,载《人民法院报》2006年4月17日。

然权利是有成本的,那么权利的实施必然涉及稀缺问题,因而不可能是绝对的”。^⑥ 对于滥诉的防止,美国法院设定了一个制裁方式:涉嫌滥用诉权的原告在提起诉讼之前首先要取得法院的许可。法院在实际制裁前通常会警告原告,如果原告无视法院的警告,就有可能受到实体制裁。^⑦ 其他如英国,刁难性或重复的申请,以及对已经公开信息的申请和将要被公布的信息的申请都被排除在外。新西兰《政府信息法》第十八条规定:“申请轻佻、无根据或无足轻重”的,“可作出拒绝决定”。在墨西哥,可以拒绝侮辱性的申请或此前已经回应过的申请。^⑧ 前述香港高等法院原讼法庭通过对马桂珍女士滥诉的禁令,明确“为了保障其它人不会受无理缠扰诉讼,以及确保法庭资源不会浪费,对于长久以来有记录证明常时会开展无理缠扰诉讼的人,司法机关可遏止这些行为。”在韩国,甚至通过刑事追究的方式制裁滥诉。2011年,韩国清州地方检察厅以“经常性虚构事实诬告”的罪名起诉74岁的A某。根据检方的调查,A某从2008年7月开始至被起诉前,对101名检察官、法官、律师、郡厅公务员、保险公司代表等通过虚构事实数十次起诉。首尔西部地方检察厅则查处了42岁的无业者、法学硕士金某利用其法学专业知识滥诉案件,其从1999年至检方起诉,共胡乱起诉126件、涉及被告239人。^⑨

对于滥诉的认定,除了形式上的起诉次数外,可以从申请人所提起的诉讼是否缺乏诉的利益、诉讼目的是否正当、是否有悖诚信几个方面进行审查。上述几个方面既决定了起诉权行使的必要性,也影响着起诉权行使的正当性。对于构成滥诉的,法院应有权明确不再受理案件,对此,已有法院作了非常好的尝试。江苏省南通市港闸区人民法院在“陆红霞不服被告南通市发展和改革委员会政府信息公开答复案”中认为:“保障当事人的诉权与制约恶意诉讼、无理缠诉均是审判权的应有之义。对于个别当事人反复多次提起轻率的、相同的或者类似的诉讼请求,或者明知无正当理由而反复提起的诉讼,人民法院对其起诉应严格依法审查。本案原告陆红霞所提起的相关诉讼因明显缺乏诉的利益、目的不当、有悖诚信,违背了诉权行使的必要性,因而也就失去了权利行使的正当性,属于典型的滥用诉权行为”。“在现行法律规范尚未对滥用获取政府信息权、滥用诉权行为进行明确规制的情形下,根据审判权的应有之义,结合立法精神,决定对原告陆红霞的起诉不作实体审理。为了兼顾维护法律的严肃性、有效利用公共资源和保障原告陆红霞依法获取政府信息、提起诉讼的权利,对于原告陆红霞今后再次向行政机关申请类似的政府信息公开、向人民法院提起类似的行政诉讼,均应依据《条例》的现有规定进行严格审查,原告须举证说明其申请和诉讼是为了满足自身生产、生活、科研等特殊需要,否则将承担不利后果。”该案例已被载入《最高人民法院公报》2015年第11期,可以作为同类案件参考。

⑥ [美]霍尔姆斯、桑斯坦:《权利的成本——为什么自由依赖于税》,毕竞悦译,北京大学出版社2004年版,第2、27页。

⑦ 参见赵正群、宫雁:《美国的信息公开诉讼制度及其对我国的启示》,载《法学评论》2009年第1期。

⑧ 转引自李广宇:《政府信息公开司法解释读本》,法律出版社2011年版,第89-90页。

⑨ 参见前引④。



结 语

我国法院通过立案审查采取选择性司法有其历史必然性,在以立案登记制取代立案审查制的当下,基于选择性司法的三大因素仍然存在,或者说在我国社会仍将处于较长时期的社会转型过程这一大背景下,立案登记制的施行必须照应现实,在坚持司法有限原则的基础上,尽快同步进行相关机制改革,以应对由此而来的司法环境的改变。

Abstract: Case-filing registration system marks the end of selective justice. However, for the People's Court in transformation period, there are profound political, social and legal reasons for it to apply selective justice in dealing with conflicts through case-filing review system. The replacement of the case-filing review system by the case-filing registration system firstly is meaningful. Firstly, it represents that in case-filing procedure, the court has transferred from the authority doctrine to protection of right of action. More importantly, there should be a big change in the judicial role or power of the court. However, the above-mentioned three factors which lead to the application of selective justice through case-filing review system still exist. In the context that our society will be in a long term of transformation, in order to balance the acceptance of each lawsuit and filing of each case and the dealing of "cases should be dealt with in accordance with law", the following issues must be managed. Firstly, balancing the relationship between registration and review in case filing procedure; secondly, establishing the notion of limited justice and specify the scope of case acceptance; thirdly, advocating resolving disputes in multiple ways and speed the establishment of compulsory mediation procedure before litigation; and lastly, regulating and preventing from improperly exercising right to action, particularly abuse of action.

(责任编辑:李小明)

